

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Poder Vinculado e Discricionário

1. Introdução

Vamos iniciar um novo tópico essencial para a compreensão do Direito Administrativo: os **poderes e deveres da administração pública**. Esse tema é fundamental, pois integra a base do Direito Administrativo e permite entender melhor outros conteúdos dentro da matéria.

O estudo desse assunto começa pela **distinção entre poder vinculado e poder discricionário**, conceitos já mencionados anteriormente ao tratar dos atos administrativos.

Naquele contexto, falou-se sobre mérito administrativo e sobre a classificação dos atos quanto à margem de liberdade que o administrador possui ao praticá-los. Agora, o objetivo é reforçar esse conhecimento para que ele fique bem sedimentado.

Antes de abordar especificamente o poder vinculado e o poder discricionário, é necessário situar o tema dentro do estudo dos poderes da administração pública. Desde o início do curso, discutiu-se o **regime jurídico-administrativo**, que se sustenta em um binômio fundamental: a **indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público**.

O Direito Público confere à administração uma série de **prerrogativas** para garantir a preservação desse interesse, mas, ao mesmo tempo, impõe diversas **restrições**.

O agente público, ao exercer sua função administrativa, está sujeito a essas limitações para que não haja comprometimento do **interesse coletivo**. Esse equilíbrio entre prerrogativas e restrições é essencial para entender o papel dos poderes administrativos.

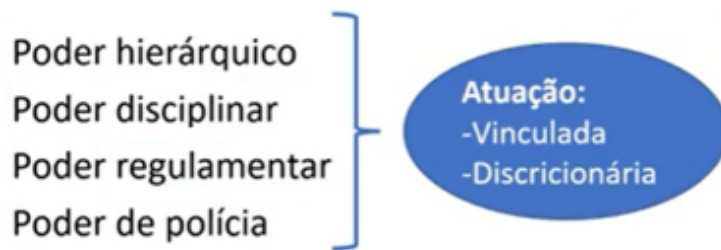
Os poderes da administração pública **não são apenas faculdades, mas também deveres**. A administração possui poderes que decorrem da relação de supremacia do interesse público, mas esses mesmos poderes se traduzem em obrigações que derivam da indisponibilidade desse interesse.

Assim, ao longo do estudo desse tema, fica claro que os poderes administrativos, em certos momentos, configuram verdadeiros deveres.

Quando se trata do poder vinculado, por exemplo, percebe-se que o administrador público não apenas pode agir, mas tem a obrigação de fazê-lo de determinada maneira, conforme previsto na legislação.

A doutrina classifica os poderes da administração pública de diferentes formas. A visão que parece mais coerente é a que estabelece quatro poderes principais: o **poder hierárquico, o poder disciplinar, o poder regulamentar e o poder de polícia**.

No entanto, há uma divergência em relação ao poder vinculado e ao poder discricionário. Algumas correntes doutrinárias não os consideram poderes autônomos, mas sim formas de atuação dos demais poderes. Ou seja, o poder hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia **podem, em determinados momentos, se manifestar de maneira vinculada ou discricionária**.



Essa diferença de interpretação pode ser relevante em provas de concurso público. Como destacado, as bancas examinadoras nem sempre seguem um único entendimento, e é possível encontrar questões que apresentam apenas os quatro poderes mencionados inicialmente.

Dependendo do contexto da questão, essa alternativa pode estar correta. Entretanto, na maioria dos concursos, costuma-se considerar que existem seis poderes administrativos: **poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia.**

Dessa forma, é essencial compreender ambas as abordagens para evitar armadilhas nas provas e saber interpretar corretamente o que está sendo cobrado.

Apesar da existência de diferentes posicionamentos, a regra geral adotada na maioria das questões de concurso reconhece os seis poderes como autônomos.

2. Poder Discricionário

O **poder discricionário** é aquele em que a administração pública tem certa **liberdade para agir conforme a conveniência e a oportunidade**, sempre **dentro dos limites estabelecidos pela lei**.

Essa margem de liberdade, porém, **não é absoluta**. A lei determina até que ponto o administrador pode exercer seu juízo de valor na aplicação desse poder, **respeitando sempre o interesse público**.

Para entender melhor esse conceito, é importante lembrar a estrutura dos atos administrativos. Cada ato administrativo possui cinco requisitos fundamentais: **competência, finalidade, forma, motivo e objeto**. Esses requisitos, conhecidos pelo acrônimo "**COFIFOMOB**", **podem ser vinculados ou discricionários**.

A **competência, a finalidade e a forma são sempre vinculadas**, ou seja, não há margem de escolha para o administrador nesses aspectos. A lei define quem é o agente competente para praticar o ato, qual a sua finalidade e a forma como deve ser realizado.

Já o **motivo e o objeto podem, dependendo do ato, ser vinculados ou discricionários**.

Se um ato administrativo for **vinculado, todos os seus elementos são determinados pela lei**, não havendo espaço para decisão subjetiva do administrador.

No entanto, se o ato for **discricionário, pelo menos um de seus elementos, motivo ou objeto, terá alguma margem de liberdade**. Basta que haja liberdade, por menor que seja, em qualquer um desses elementos para que o ato seja considerado discricionário.

Um exemplo prático disso pode ser observado na aplicação de multas em contratos administrativos. A Lei 14.133/21 estabelece que a administração pode aplicar multas variando entre 0,5% e 30% sobre o valor do contrato.

Ainda que a aplicação da multa seja obrigatória e esteja prevista na legislação, **há um espaço para decisão quanto ao percentual exato dentro desse intervalo**. Isso significa que, mesmo sendo uma liberdade reduzida, a decisão sobre o percentual a ser aplicado torna o ato discricionário.

Esse entendimento é essencial para provas de concurso, pois muitas questões tentam confundir o candidato ao apresentar situações em que há uma vinculação geral, mas ainda existe um pequeno grau de liberdade. O essencial é lembrar que qualquer espaço de escolha por parte da administração, **mesmo que mínimo, já caracteriza o ato como discricionário**.

O poder discricionário pode ser observado em diversas situações práticas dentro da administração pública. Um exemplo clássico é encontrado no poder disciplinar, conforme previsto na Lei 8.112, que rege o estatuto dos servidores públicos federais.

Essa lei estabelece que determinadas infrações cometidas por servidores são passíveis de advertência, e que, em caso de reincidência, pode ser aplicada uma suspensão.

A suspensão, por sua vez, deve obedecer a um prazo máximo de 90 dias. Isso significa que o administrador público tem liberdade para escolher a duração da suspensão dentro desse limite, podendo aplicá-la por um dia, 10 dias, 30 dias ou até o máximo permitido.

No entanto, ultrapassar esse período não é permitido, pois violaria os limites impostos pela lei. Esse exemplo ilustra bem a ideia de que o poder discricionário não é absoluto, mas sim exercido dentro de uma margem de liberdade estabelecida previamente.

Outro exemplo semelhante é o da aplicação de multas em contratos administrativos. Se uma legislação determina que a penalidade pode variar entre 4% e 5% do valor do contrato, a administração tem o poder de decidir dentro desse intervalo.

No entanto, aplicar uma multa fora desses limites, seja menor que 4% ou maior que 5%, configuraria um ato ilegal, pois extrapolaria a margem de discricionabilidade permitida.

A desapropriação de imóveis também exemplifica bem o poder discricionário. A administração pública pode desapropriar bens para a realização de obras ou serviços que atendam ao interesse público, como a construção de uma escola ou de uma estrada. No entanto, não há uma norma que determine especificamente qual imóvel deve ser desapropriado.

A escolha do bem a ser expropriado cabe ao administrador, que decide com base na conveniência e na necessidade da coletividade. A lei apenas define o procedimento que deve ser seguido, mas a decisão sobre qual imóvel será desapropriado permanece discricionária, sempre fundamentada no interesse público.

Dentro do poder discricionário, dois princípios fundamentais precisam ser considerados: o **princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade**.

Esses princípios determinam que a administração pública deve agir de maneira equilibrada, escolhendo **meios adequados para atingir a finalidade pública, sem excessos ou insuficiências**. Isso significa que o administrador, ao tomar uma decisão discricionária, precisa garantir que sua escolha seja suficiente para alcançar o interesse público, mas sem ir além do necessário.

O ponto essencial aqui é que **esses princípios só podem ser exigidos nos atos discricionários**. Isso ocorre porque, no ato vinculado, não há qualquer margem de escolha para o administrador.

Ele não age com base em juízo próprio, mas sim seguindo estritamente o que está previsto na lei. Como a decisão já está determinada, não há como exigir razoabilidade ou proporcionalidade, pois o administrador não tem opção de escolha. Assim, esses princípios fazem sentido apenas nos atos em que há liberdade de decisão.

Outro ponto relevante é a **possibilidade de controle judicial sobre atos discricionários**. Muitas pessoas ainda possuem dúvidas sobre até onde o poder judiciário pode intervir nesses atos.

A resposta é que, embora o judiciário **não possa interferir no mérito administrativo**, ele tem **competência para analisar a legalidade do ato**.



Fique ligado!

Isso significa que **o controle judicial pode incidir sobre os elementos vinculados do ato administrativo, como competência, finalidade e forma, além de verificar se a margem de discricionariedade respeitou os limites estabelecidos pela lei.**

O exemplo da suspensão de servidores públicos ilustra bem essa questão. Conforme a Lei 8.112, a penalidade pode variar de um a 90 dias. Dentro desse intervalo, a escolha do tempo de suspensão é discricionária, sendo um aspecto do objeto do ato. No entanto, outros elementos do ato, como competência, finalidade e forma, são vinculados.

Além disso, o motivo da suspensão também é um elemento vinculado, pois a lei já determina quais infrações podem levar a essa penalidade. Assim, caso um administrador aplique uma suspensão de 100 dias, estaria extrapolando os limites da discricionariedade, o que permitiria ao judiciário anular o ato por ilegalidade.

Portanto, mesmo quando há poder discricionário, essa liberdade não é absoluta. O judiciário pode intervir sempre que o administrador ultrapassar os limites legais, garantindo que a administração pública atue dentro da legalidade e em conformidade com os princípios que regem sua atuação.

Mesmo dentro dos limites legais, um ato administrativo discricionário pode ser considerado ilegal se desobedecer aos princípios da administração pública. Isso acontece porque a legalidade analisada pelo judiciário não se restringe apenas ao cumprimento literal da lei, mas deve ser entendida em um sentido amplo.

Ou seja, um ato administrativo pode estar formalmente em conformidade com a legislação, mas, se contrariar princípios como moralidade, impessoalidade ou eficiência, ainda assim poderá ser anulado por ilegalidade.

Um exemplo claro disso pode ser observado nos concursos públicos. A administração pública tem certas decisões discricionárias ao longo do processo, mas essa discricionariedade não é irrestrita. Uma dessas decisões envolve a nomeação dos candidatos aprovados.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital têm direito líquido e certo à nomeação. A Constituição Federal estabelece que o prazo de validade de um concurso pode ser de até dois anos, prorrogável por mais dois.

A administração tem discricionariedade para definir esse prazo dentro desse limite. Suponha que um concurso tenha validade de um ano, prorrogável por mais um. Durante esse período, a administração pode escolher o momento mais oportuno para nomear os aprovados, desde que respeite o prazo final.

O problema surge quando a administração não realiza a nomeação dentro do prazo estabelecido. Nesse caso, a discricionariedade foi ultrapassada, pois a omissão da administração feriu o direito dos candidatos aprovados.

Mesmo sendo um ato discricionário, essa omissão pode ser questionada judicialmente, e o poder judiciário tem competência para determinar a nomeação dos candidatos prejudicados. O controle judicial, nesse caso, não incide sobre o mérito administrativo, mas sobre a legalidade da conduta da administração, garantindo que o ato discricionário não ultrapasse os limites permitidos.



Tome nota!

PODER DISCRICIONÁRIO:

- **Conveniência e oportunidade** (mérito administrativo, interesse público);

- Princípio da **razoabilidade e proporcionalidade** (Só é exigido nos atos discricionários);
- Controle do poder judiciário:
 - Não controla mérito administrativo;
 - **Controla a legalidade.**

3. Poder Vinculado

O **poder vinculado**, ao contrário do poder discricionário, **não concede qualquer margem de liberdade ao administrador público.**

Trata-se de um poder em que a administração pública pratica um ato porque a lei determina exatamente como ele deve ser realizado, **sem possibilidade de escolha ou juízo de conveniência.**

Diferente do poder discricionário, onde a lei estabelece parâmetros dentro dos quais o administrador pode decidir, no poder vinculado a decisão já está previamente definida, **cabendo ao administrador apenas cumprir o que foi determinado.**

Um exemplo claro de ato vinculado é a demissão por abandono de cargo, prevista na Lei nº 8.112. Se um servidor público faltar ao trabalho por 30 dias consecutivos, sem justificativa, a penalidade aplicada será obrigatoriamente a demissão. **Não há qualquer margem para o administrador decidir se a penalidade será mais branda ou aplicada de maneira diferente.**

Não há possibilidade de graduar a punição, como ocorre na suspensão, que pode variar de 1 a 90 dias. Nesse caso, a única alternativa prevista pela lei é a demissão, tornando o ato completamente vinculado.

Outro exemplo é a concessão de licença para construir. Quando um particular solicita essa licença junto à administração pública, o papel do administrador é apenas verificar se os requisitos legais foram atendidos.

Se todos os documentos exigidos estiverem corretos e de acordo com a legislação, a administração pública é obrigada a conceder a licença, **sem qualquer possibilidade de recusa baseada em juízo próprio.**

Por outro lado, se algum requisito não for atendido, a licença deve ser negada, mas não por escolha do administrador, e sim porque a legislação exige o cumprimento de determinadas condições. Ou seja, **a decisão não envolve conveniência ou oportunidade, apenas a aplicação estrita da norma.**

Nos atos vinculados, todos os elementos do ato administrativo são igualmente vinculados. Isso significa que não há qualquer espaço para discricionariedade em relação à competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O administrador simplesmente segue o que está determinado na lei, sem poder avaliar ou escolher alternativas.

Assim, ao contrário do poder discricionário, no qual princípios como razoabilidade e proporcionalidade podem ser exigidos, no poder vinculado esses princípios não se aplicam, pois não há margem para que o administrador tome uma decisão baseada em juízo subjetivo. A atuação é puramente técnica e legal, sem qualquer interferência de vontade pessoal.

Portanto, o poder vinculado se caracteriza pela total ausência de liberdade decisória do administrador, garantindo previsibilidade e segurança jurídica na atuação da administração pública. O administrador apenas cumpre o que já está estabelecido na norma, sem possibilidade de flexibilização ou escolha.



Tome nota!

PODER VINCULADO:

- **Não existe liberdade.**

Resumo

Poder Discricionário

- Permite ao administrador público decidir conforme conveniência e oportunidade, dentro dos limites impostos pela lei.
- Características:
 - Existe uma margem de liberdade para decidir.
 - Decisão deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
 - Não é um poder absoluto; a discricionariedade tem limites legais.
- Elementos do Ato Discricionário:
 - Vinculados: Competência, finalidade e forma.
 - Podem ser discricionários: Motivo e objeto (dependendo do ato).
- Se pelo menos um elemento for discricionário, o ato será considerado discricionário.
- Controle Judicial:
 - O mérito administrativo (escolha dentro da discricionariedade) não pode ser revisto pelo Judiciário.
 - O Judiciário pode analisar competência, finalidade, forma e limites da discricionariedade.
 - Se o administrador ultrapassa o limite legal.

Poder Vinculado

- Ato administrativo no qual não há margem de escolha para o administrador; a lei determina exatamente como deve ser feito.
- Características:
 - Não há liberdade para decidir.
 - Todos os elementos do ato administrativo são vinculados: Competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
- Controle Judicial:
 - O Judiciário pode analisar todos os elementos do ato, pois são integralmente vinculados.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960